

1503890-79.2021.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/02/2022
... da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
1ª Vara Criminal
Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503890-79.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503890-79.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica (Violência Doméstica Contra a Mulher)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIEL THOMAZ DOS SANTOS

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

DANIEL THOMAZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 129, §13, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, nas condições de tempo e espaço descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, por razões da condição do sexo feminino, agrediu V.C.J., com quem manteve relacionamento amoroso, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas na denúncia. Ao final, foi o réu interrogado.

Realizados os debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à dosimetria da pena e fixação do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, por falta de provas. Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à fixação da pena, requerendo o afastamento da circunstância agravante relativa ao estado de calamidade pública, alegando que norma penal em branco somente poderia ser suprida por decreto federal, que não foi renovado para o ano de 2021. Pediu a aplicação do §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal e formulou pedidos relativos à fixação do regime prisional.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar arguida pela combativa Defesa relativa à nulidade da prova produzida por não guardar relação com a denúncia, que descreveu data diversa daquele em que ocorreram os fatos, deve ser afastada.

É inegável o erro material contido na denúncia, uma vez que o mês descrito na data dos fatos diverge daquele constante no boletim de ocorrência.

Entretanto, a completa descrição de todos os fatos e circunstâncias em que eles ocorreram possibilitou o irrestrito exercício da ampla defesa.

Outrossim, a Defesa não demonstrou, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, ter ocorrido qualquer prejuízo ao acusado quanto ao mero erro material contido na denúncia no tocante à data do fato.

No mérito, a materialidade do delito está demonstrada de forma inequívoca pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 129/130, pela fotografia de fls. 15, pelo boletim de ocorrência e demais elementos constantes nos autos.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que, na data dos fatos, foi à festa de um amigo de infância, onde a vítima já estava e esta embriagou-se. Contou que puxou a vítima a fim de conversarem, porém ela o empurrou e, ao puxá-la novamente, ela caiu no chão e machucou-se. Alegou que não tinha intenção de causar lesões na vítima, pois possuem boa convivência, relacionando-se há mais de um ano. Disse que, no momento em que o policial o algemou, estava alterado, pois já estava nervoso em razão de ciúmes da vítima e, após, pela chegada da equipe policial. Declarou que não conhecia os policiais que o abordaram anteriormente aos fatos e não soube dizer se eles possuíam algum motivo para prejudicá-lo ao narrar terem presenciado as agressões contra a vítima. Contou que todos os machucados da vítima foram decorrentes de sua queda, após tê-la puxado. Disse que a vítima enviou-lhe uma carta, durante o período em que se encontra detido, dizendo ter-se ferido no rosto após ter caído no chão, mas não soube se foi essa a versão que a vítima apresentou na delegacia. Declarou que a vítima é autônoma, possui dois filhos, mas não estava trabalhando à época dos fatos, sendo que ela auxiliava nos cuidados com sua mãe, sogra dela. Disse que trabalhava como ajudante de cozinha e auxiliava a vítima no sustento dos filhos dela. Contou que não a vítima nunca esteve embriagada como ocorreu na data dos fatos. Declarou que a polícia foi chamada ao local em razão da discussão entre as partes. Esclareceu que a vítima tentou manter contato consigo, por carta, durante o

tempo de sua prisão, demonstrando intenção de manter o relacionamento.

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que estava com o acusado, divertindo-se na casa de um amigo daquele, quando ocorreu uma discussão sem importância entre ela e o réu. Disse que, após a discussão, virou-se de costas e o réu a puxou, momento em que caiu. Relatou que sua queda possivelmente ocorreu em razão de ter sido puxada, uma vez que o acusado nunca a havia agredido. Declarou que uma viatura policial passou pelo local no momento em que ocorriam os fatos e ambos foram levados à delegacia. Esclareceu que, quando questionada sobre os fatos em solo policial, disse que o réu a havia puxado, ocasionando sua queda. Relatou que o acusado não a agrediu, nem desferiu soco em suas costas. Contou que o acusado não possui porte físico muito maior que o seu, porém, ao puxá-la, por ser mais forte, fez com que se desequilibrasse e caísse. Declarou, então, que empurrou o acusado primeiro, sem agredi-lo e, então, o acusado a empurrou, causando sua queda. Disse que um casal de conhecidos presenciaram os fatos. Narrou que mantinha relacionamento com o acusado, mas não possuíam filhos em comum e nada semelhante havia ocorrido anteriormente aos fatos. Relatou que não rompeu o relacionamento com o acusado, mas, em razão de sua prisão, não mantém contato com ele e pretende discutir acerca da manutenção do relacionamento posteriormente. Disse que policiais foram chamados ao local dos fatos, mas não soube dizer quem os acionou. Contou, então, que havia passado uma viatura no momento dos fatos e os policiais pararam para saber o que estava ocorrendo, sendo que, ao sair da casa, outra viatura já estava no local, sendo ela e o réu conduzidos à delegacia em viaturas distintas. Questionada sobre as lesões constatadas no laudo pericial, disse que não ocorreram agressões e que aquelas foram causadas por sua queda no chão onde havia pedras, após ter sido empurrada pelo acusado. Então, tornou a declarar que o réu apenas a puxou e, porque estava usando chinelos, escorregou e caiu, o que causou os ferimentos. Declarou que não era de sua vontade que o réu fosse preso. Disse que não foi procurada por ninguém a fim de alterar seu depoimento e que não se sente ameaçada pelo réu. Relatou que, em sua percepção, o réu não tinha intenção de machucá-la quando a puxou. Disse que sua narrativa apresentada em Juízo foi a mesma fornecida em solo policial. Disse que os fatos ocorreram na garagem da casa e era possível, a quem estivesse do lado externo, ver o que estava ocorrendo dentro do local. Disse que, no momento em que estavam discutindo e que empurrou o réu, a viatura policial ainda não havia chegado e que sua queda ocorreu quase na calçada, onde havia pequenas pedras, sendo que os policiais que passavam pelo local viram a confusão e também a viram machucada. Disse ter fornecido esta mesma versão aos policiais militares, afirmando a eles que não precisava de atendimento, porém a policial feminina disse que a levaria à delegacia.

A testemunha policial militar Magma da Silva, ouvida em Juízo, narrou que, acionada sua equipe policial, via Copom, para atendimento de ocorrência relativa à agressão, deslocou-se ao local indicado, onde estava ocorrendo uma festa. Disse que o responsável pela casa e pela festa informou que as partes estavam brigando dentro de sua residência. Narrou que, autorizada a entrada da equipe no local, viu o acusado agredindo a vítima com socos. Relatou que interveio e foi necessário uso moderado de força para algemar o acusado, devido ao estado do acusado, alterado e agressivo. Asseverou que a vítima apresentava lesões na cabeça, no lábio superior, no ombro esquerdo e nos dois joelhos, mas recusou atendimento médico. Afirmou que presenciou a agressão praticada pelo acusado contra a vítima, com socos. Consignou que as lesões apresentadas pela vítima aparentavam ser recentes. Declarou que, em contato com a vítima, esta lhe disse que estava na festa com o réu, ambos discutiram, ele tentou agredi-la, sendo impedido por amigos e, durante a confusão, ela caiu. Disse que o réu declarou apenas ter ocorrido uma discussão de casal.

A testemunha policial militar Juliano Donaire Peres, também ouvido em Juízo, relatou que, atendendo ocorrência noticiada via Copom, foi ao local indicado, onde era realizada uma festa e o responsável pelo local informou que um casal de amigos estaria brigando aos fundos da casa, pedindo que a equipe entrasse no local.

Afirmou que, no corredor da casa, viu a vítima correndo e o réu dando socos nas costas dela. Disse que o acusado estava nervoso e comportava-se de forma alterada, sendo detido. Relatou que a vítima estava bastante machucada e disse à sua equipe que havia caído no quintal durante a discussão com o réu. Consignou, contudo, que presenciou a agressão praticada pelo réu, razão pela qual conduziu as partes à delegacia, tendo ambos recusado atendimento médico. Esclareceu que presenciou apenas o soco desferido pelo acusado contra a vítima e o momento em que esta correu na direção da equipe policial. Declarou que os ferimentos da vítima aparentavam ser recentes. Não recordou como era a estrutura do local dos fatos, mas esclareceu que o piso era sextavado e o muro de cimento. Narrou que, no local dos fatos, nenhuma pessoa forneceu declarações, tendo somente o proprietário informado que a briga entre as partes iniciou-se em razão de ciúmes. Esclareceu que este responsável pelo local não foi conduzido à delegacia, tendo sido apenas arrolado como testemunha no boletim de ocorrência da Polícia Militar, pois informou que não viu os fatos, mas apenas ouviu. Disse que os participantes da festa estavam consumindo bebida alcoólica, mas não viu se a vítima ingeriu bebidas. Esclareceu que, no momento em que a equipe policial ingressou na casa, viu o acusado desferir soco na vítima e esta correu na direção da equipe, dizendo que o réu queria agredi-la, narrando, posteriormente, que havia caído. Não recordou se a vítima apresentava machucado nas costas, mas estava com o ombro ferido. Não recordou se a vítima disse ter agredido o réu.

Dessa forma, em que pese a vítima, em Juízo, tenha oferecido versão distinta daquela por ela apresentada em solo policial, nada há nos autos para desacreditar o relato extrajudicial da vítima, no sentido de que foi empurrada pelo acusado, conduta esta que ocasionou sua queda e foram a razão de seus ferimentos, mesmo porque as lesões por ela afirmadas naquela oportunidade restaram demonstradas por prova técnica, que não foi contrariada com fundamentos também técnicos por qualquer das partes.

Com efeito, a lesão leve sofrida pela vítima foi atestada pelo laudo pericial de fls. 129/130 e podem também ser constatadas pela fotografia de fls. 15, sendo absolutamente compatível com as agressões por ela narradas na fase inquisitiva.

Em que pese a vítima ter, em diversos momentos de suas declarações judiciais, narrado que havia empurrado o réu e este apenas a puxou, o que fez com que se desequilibrasse por estar usando chinelos e acabasse por cair sobre pedras, é possível observar que, também por diversas vezes, declarou que o réu a havia empurrado, fazendo com que caísse.

Depreende-se das declarações da vítima que, em todos os momentos em que ela forneceu narrativa no sentido de que o acusado a havia empurrado, confirmando sua versão extrajudicial, procurava, na sequência, beneficiar o acusado, dizendo que ele apenas a teria puxado e que sua queda se deu por desequilíbrio.

Embora negando a vítima que o acusado causou-lhe lesões corporais de forma intencional, negando, também, que tenha sido golpeada com socos desferidos pelo réu, suas declarações em Juízo mostram-se inseguras, diante das contradições ao longo de sua oitiva, já evidenciadas, bem como diante dos depoimentos das testemunhas policiais que afirmaram ter visto o momento em que o réu agredia a vítima com socos.

Veja-se que os relatos das testemunhas policiais militares mostram-se coerentes e harmônicos com aqueles apresentados à Autoridade Policial, nada havendo nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente por eles e, portanto, nada havendo nos autos a desacreditar as versões por elas fornecidas

Note-se que as testemunhas não presenciaram o que teria ocorrido anteriormente ao

golpe de soco praticado pelo réu contra a vítima e, portanto, não viram de que forma ocorreram as lesões apresentadas pela vítima.

Contudo, afirmaram que foram acionadas ao local dos fatos em razão de um desentendimento entre um casal e, lá, apuraram junto ao responsável pela casa e pela festa que as partes estavam brigando. Consignaram que, então, puderam testemunhar o réu agredindo a vítima com socos nas costas.

Observe-se, ainda, que a testemunha Juliano acrescentou que a vítima, inicialmente, correu na direção da equipe policial quando estava sendo agredida com soco e disse que o réu queria agredi-la, porém, na sequência, a vítima informou que ela havia caído.

Asseveraram, também, as testemunhas que puderam constatar que a vítima apresentava lesões com aspecto de recenticidade.

A reunião de todos estes elementos acima elencados fornece a certeza necessária de que o acusado efetivamente praticou as agressões contra a vítima, causando as lesões corporais descritas no laudo pericial.

Por fim, a negativa do acusado quanto às agressões praticadas pela vítima, encontra-se isolada no contexto probatório.

Não há qualquer dúvida de que o acusado efetivamente praticou as agressões contra a vítima na data dos fatos, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fls. 129/130, praticando o crime descrito na denúncia.

A conduta da vítima em tentar, em Juízo, isentar de responsabilidade seu agressor se justifica pela sua evidente dependência, tanto financeira como psicológica e emocional.

É extremamente comum o medo que a mulher tem de romper com tudo e de recomeçar sua vida, mantendo-se sozinha, não acreditando, muitas vezes, que isso será possível, diante de vários fatores, como incapacidade financeira para integral subsistência própria e de seus filhos, o que foi, inclusive, descrito pelo acusado.

Com isso, a mulher, vítima de violência doméstica, acaba se submetendo a viver com seu agressor mesmo sofrendo reiteradas violências.

Apesar de se entender essa difícil situação, importante que a mulher busque ajuda profissional para conseguir se desvincular desse ciclo de violência em que vive e encontrar meios próprios para seguir sua vida.

Feitas essas considerações, passo à dosagem da pena do crime de lesão corporal segundo o critério previsto no artigo 68 do Código Penal.

Levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 Código Penal, observo que o réu não pode ser considerado como detentor de Maus antecedentes e não há outras razões para o aumento da pena-base acima do mínimo legal, ficando ela fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o réu é reincidente, conforme certidão criminal de fls. 16/17, devendo ser a pena aumentada em 1/6, ficando fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública.

Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública.

Ressalte-se que, segundo o artigo 61 do Código Penal, dentre as circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, têm-se:

“j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;” (grifei)

Inicialmente, observa-se que o dispositivo penal é expresso em determinar que a hipótese de agravante é qualquer calamidade pública, não havendo nenhum tipo de restrição no sentido de que somente calamidades públicas no âmbito federal caracterizariam a agravante.

De outro lado, não se nega que Municípios e Estados da Federação também têm a competência de editar decretos reconhecendo-se o estado de calamidade pública.

Assim, feita esta primeira observação, verifica-se que se está diante de norma penal em branco, cujo conceito é trazido por Luiz Régis Prado:

A lei ou norma penal em branco pode ser conceituada como aquela em que a descrição da conduta punível se mostra lacunosa ou incompleta, necessitando de outro dispositivo legal para sua integração ou complementação. Essa afirmação significa dizer que o preceito, hipótese legal (preceito ou prótase) é formulada de maneira genérica ou indeterminada, devendo ser preenchida colmatada ou determinada por ato outro normativo (legislativo ou administrativo) em regra, de cunho extrapenal, que fica pertencendo, para todos os efeitos, à lei penal. [...]. (PRADO, L. R. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte geral. V.1. São Paulo: RT, 2010.)

A norma penal em branco será heterogênea quando o complemento é oriundo de fonte diferente da que editou a norma principal.

Heleno Cláudio Fragoso define a norma penal em branco heterogênea como sendo uma descrição da conduta incriminadora do direito penal que necessita ser complementada por outra norma já existente ou futura, mas de fonte legislativa diversa.

Portanto, admite-se que o complemento das normas penais em branco heterogêneas, podem advir de fonte diversa da União e por órgão distinto do poder legislativo, ou seja, do Poder Executivo Estadual ou Poder Executivo Municipal. (FRAGOSO, H. C. Lições de Direito Penal (parte geral). 16.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.)

Segundo Nelson Hungria, os regulamentos, portarias ou editais integram a norma penal, pois com ela passam a fazer corpo ou unidade lógica.

Trata-se de um caso típico de lei penal em branco: seu complemento são as eventuais determinações do poder público (mediante editais ou portarias, oficialmente publicadas para o conhecimento geral) concernentes a medidas preventivas contra a incursão ou difusão de moléstia contagiosa (isto é, transmissível por contágio). Tais medidas poderão ter, ou não, base em regulamento permanente. Poder público quer dizer, aqui, autoridade competente (federal, estadual ou municipal). (Comentários ao Código Penal, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1977, v. 1, t. 1, ps.102, n. 7. 66)

Portanto, pode o complemento da lei penal em branco ser elaborado por autoridades municipais e estaduais, apesar de só a União poder legislar sobre Direito Penal,

tratando-se de excepcionalidade somente essa complementação por órgão outro que não aquela.

Nesse sentido é o entendimento doutrinário:

“Quando se tratar de normas penais em branco heterogêneas, frise-se que “se utilizam de fontes formais heterogêneas, porque o órgão legiferante é diverso. Como exemplo ilustrativo podemos indicar o crime contra a economia popular, referente à transgressão da tabela de preços, que é fixada por órgão do Poder Executivo, através de regulamento federal, leis ou regulamentos estaduais ou municipais, tem como complemento da lei penal em branco um complemento de diferente fonte normativa” (Nucci, Guilherme de Souza, editora RT, 2. ed., 2002)

“É a determinação do poder público. O “poder público” que baixa a determinação pode ser qualquer autoridade (federal, estadual, distrital ou municipal) competente para o ato, a qual deve constar do rol de suas atribuições legais. Cuida-se, portanto, de lei penal em branco, pois seu preceito primário depende de complementação, a qual pode ser veiculada por outra lei (lei penal em branco homogênea ou lato sensu) ou por algum ato administrativo (lei penal em branco heterogênea ou stricto sensu)”. (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 212) – Volume 2. 12ª edição. São Paulo: Editora Método, 2019, p.11.)

Conclui-se que Estados e Municípios têm competência para editarem o complemento de normas em branco heterogêneas, não se podendo falar em violação ao princípio da legalidade, pois a fonte legislativa diversa apenas complementa os elementos da tipicidade formal já indicados pela lei federal.

Finalmente, a agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime.

Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. A pena deve ser acrescida de 1/6, ficando fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a reprimenda acima estabelecida.

Em que pese ser o réu reincidente em crime doloso, diante das circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de sua pena.

Nos termos do artigo 41 da Lei nº 11.340/06, bem como diante da reincidência do acusado, não é cabível a suspensão condicional do processo.

Por se tratar de lesão corporal praticada na forma de violência doméstica, bem como diante de sua reincidência, não poderá o réu beneficiar-se da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Diante de sua reincidência, também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DANIEL THOMAZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se a gravidade do delito por ele praticado. Outrossim, o acusado é reincidente. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Observe-se que seria um contrassenso soltá-lo após responder ao processo preso, somente por ter recebido reprimenda no regime semiaberto, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição, como já exposto, inexistindo qualquer incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS - Roubo (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Pretensão à liberdade provisória. Inadmissibilidade. Pacientes permaneceram presos durante a instrução criminal. Inexistência de alteração fática substancial apta a permitir a concessão do pleito. Presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar. Decisão suficientemente fundamentada. Guias de recolhimento provisória expedidas. Iminente remoção dos pacientes para estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto imposto na r. sentença. Inexistência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2096987-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 2ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 22/06/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉ PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante - a agravante, um corréu e uma menor de idade transportavam de um Estado para o outro considerável quantidade de entorpecentes de alto poder lesivo (17,250kg de cocaína e 14,5g de maconha), além de R\$ 420,00 em espécie.

3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo a paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.

4. As condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. No que concerne à alegada incompatibilidade da prisão preventiva diante do regime imposto na sentença (semiaberto), verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar que não se vislumbra ser o caso de exame da questão de ofício, mormente porque prolatada a sentença condenatória foi determinada a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução.

7. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes.

3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que

fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido." (RHC 140.941/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Outrossim, providencie-se o necessário para a transferência do réu a estabelecimento prisional compatível com o regime para cumprimento de pena imposto.

Finalmente, em razão das peculiaridades do presente caso, mostrando-se importante, como já ressaltado, que a vítima em situações de violência doméstica busque ajuda profissional para conseguir se desvincular desse ciclo de violência em que vive e encontrar meios próprios para seguir sua vida, verifico que a vítima deve ser encaminhada a atendimento especializado para orientação e acompanhamento de pessoas em situação de ameaça ou violação de direitos.

Assim, intime-se a vítima para que forneça seu endereço atualizado, a fim de ser direcionada ao CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Proteção Social Especial de Média Complexidade - mais próximo de sua residência (CREAS - Área Continental - Rua Frei Damião, 970 - Jd Rio Branco ou CREAS - Área Insular (Rua Lima Machado, 245 - Parque Bitaru), expedindo-se ofício ao Centro de Referência para encaminhamento da vítima.

Da mesma forma, em razão do já exposto, imponho ao acusado, cumulativamente com a pena corporal já fixada, o comparecimento obrigatório a programas de recuperação e reeducação, como cursos e palestras, a serem definidos pelo Juízo da Execução, na forma do artigo 152, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais.

Observe-se que não se trata de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas, sim, aplicação cumulativa da medida prevista no artigo 152 da Lei das Execuções Penais.

Destaque-se que a Súmula nº 588 do E. Superior Tribunal de Justiça não abre qualquer exceção legal: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Outrossim, como bem ressaltado pela Exma. Des. Ely Amioka, no Acórdão nº 0001270-50.2015.8.26.0320 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, "(...) a determinação de comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, prevista no art. 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, é cumulativa, e não substitutiva da pena privativa de liberdade, podendo ser realizada a critério do Magistrado.

Neste sentido, adoto os brilhantes argumentos do E. Desembargador Amaro Thomé, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 0013701-24.2011.8.26.0590/500013 (grifo nosso):

"A Lei Maria da Penha surgiu para salvaguardar a mulher de todas as formas de violência (não só física, mas moral e psíquica), inclusive naquelas hipóteses em que a agressão possa não parecer tão violenta. (Informativo nº 506 do STJ).

Inclusão em grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica encontra amparo legal no parágrafo único do art. 152 da LEP e ecos no art. 79 do Código Penal.

O art. 45 da Lei Maria da Penha acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei de

Execuções Penais, prevendo que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, durante o cumprimento da limitação de final de semana. Como em crimes praticados com violência é descabida a substituição da pena privativa da liberdade, resta como opção para afastamento do cárcere a suspensão condicional da pena, que, por força do art. 78 e 79 do Código Penal e do art. 158 da Lei nº 7.210/84 pode contemplar, como condição a que fica sujeito o condenado, a limitação de final de semana.

Fica evidente dos textos legais que a determinação da frequência ao grupo reflexivo não é obrigatória, nem automática, e por isso necessariamente tem que ser fundamentada, e prever prazo específico, que deve ser fixado na decisão, até para possibilitar ao condenado conhecer as condições que terá de cumprir.

Nessa ordem de ideias, relevante destacar que o artigo 152 da LEP prevê uma faculdade conferida ao magistrado, e não uma obrigatoriedade: "... Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação." Conclui-se, portanto, que a possível determinação judicial no sentido de que sejam ministrados ao condenado cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas durante o tempo que permanecer na instituição indicada pelo juiz para cumprir a pena restritiva de direito de limitação de fim de semana, não consiste em medida alternativa, como se substitutiva fosse, nos moldes do art. 44 do Código Penal. Consiste apenas em condenação acessória, incidente apenas nas hipóteses em que outorgada a suspensão condicional da pena, e tem por objetivo conferir às mulheres, vítimas de crimes desta natureza, uma resposta mais efetiva do Poder Judiciário, no sentido da ressocialização dos condenados, a ser implementada em caso de necessidade, segundo avaliação judicial, em conjunto com outras medidas determinadas para o cumprimento do sursis.

Este tipo de pena consiste na obrigação do agressor de permanecer, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado (art. 48, CP).

Este seria, portanto, o modo para o agressor cumprir sua pena e ainda refletir sobre o seu comportamento e conhecer outras formas de construção da masculinidade, para além daquela baseada no uso da força, do domínio e da violência sobre a mulher.

Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts. 44, 48 e 77 a 79, todos do Cód. Penal, 1º a 4º, 16 e 41 a 45, da Lei nº 11.340/06, para se concluir que o legislador jamais pretendeu criar a possibilidade de converter penas privativas de liberdade em restritivas de direito nos casos de crimes envolvendo violência doméstica, sobretudo no que diz com a natureza da infração e os males que ela provoca no seio social e familiar, devendo o infrator experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua conduta." (TJSP; Apelação 0001270-50.2015.8.26.0320; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira -1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 07 de janeiro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA